

헌법재판소 2026. 2. 26. 선고 2021헌마942 전원재판부

【금치처분취소등】 , [헌공제353호,643]

【판시사항】

가. 일부 청구에 대하여 공권력 행사의 존재가 부인된 사례

나. 피청구인 ○○교도소장의 2020. 9. 10.자 금치 21일 처분(이하 ‘이 사건 금치처분’이라 한다)에 대한 심판청구가 보충성 요건을 갖추었는지 여부(소극)

다. 피청구인 ○○교도소장의 2020. 9. 23.자 변색 안경 사용·소지 신청 불허가 행위(이하 ‘이 사건 사용·소지 불허가 행위’라 한다)에 대한 심판청구가 보충성 요건을 갖추었는지 여부(소극)

라. 피청구인 ○○교도소장의 2020. 10. 23.자 정보 비공개 결정(이하 ‘이 사건 제1비공개 결정’이라 한다), 2020. 10. 29.자 정보 부분 공개 결정(이하 ‘이 사건 부분 공개 결정’이라 한다), 2021. 6. 24.자 정보 비공개 결정(이하 ‘이 사건 제2비공개 결정’이라 한다)에 대한 심판청구가 보충성 요건을 갖추었는지 여부(소극)

마. 피청구인 □□교도소장의 2021. 5. 10.자 관심대상수용자 지정 행위(이하 ‘이 사건 지정 행위’라 한다)에 대한 심판청구가 보충성 요건을 갖추었는지 여부(소극)

바. 피청구인 □□교도소장이 2021. 5. 13.부터 5. 27.까지 부과한 금치 기간 중 도서 열람 제한 행위(이하 ‘이 사건 제2열람 제한 행위’라 한다)에 대한 심판청구가 보충성 요건을 갖추었는지 여부(소극)

【판결요지】

가. 기록에 의하면, 스마트워치 등의 사용·소지 불허가 행위, 접견 제한 행위, 영상계호 거실 수용·계호 행위, 2020. 11. 9.자 열람 제한 행위가 있었던 사실을 인정할 만한 자료가 없으므로, 이에 대한 심판청구는 모두 헌법소원의 대상이 되는 공권력의 행사가 존재하지 아니한다.

나. 이 사건 금치처분은 형집행법 제107조 에 의한 행정처분에 해당하여 행정심판 및 행정소송의 대상이 되는데, 청구인이 이러한 구제절차를 거쳤음을 인정할 자료가 없으므로, 이 부분 심판청구는 보충성 요건을 갖추지 못하였다.

다. 청구인에게는 소장에게 자비에 의한 물품 구매를 요구할 법률상 신청권이 인정되므로 이를 거부하거나 방치한 행위는 행정심판 및 행정소송의 대상이 되는데, 청구인이 이러한 구제절차를 거쳤음을 인정할 자료가 없으므로, 이 사건 사용·소지 불허가 행위에 대한 심판청구는 보충성 요건을 갖추지 못하였다.

라. ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’은 정보공개 청구인이 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복이 있는 때에는 이의신청, 행정심판, 행정소송의 구제절차를 밟을 수 있도록 규정하고 있는데, 청구인이 이러한 구제절차를 거쳤음을 인정할 자료가 없으므로, 이 사건 제1, 제2비공개 결정 및 이 사건 부분 공개 결정에 대한 심판청구는 보충성 요건을 갖추지 못하였다.

마. 관심대상수용자로 지정되면 편지 수수, 생활, 상담 등의 측면에서 일반 수용자들과는 다른 처우를 받을 수 있는 지위에 놓이게 된다. 즉, 이 사건 지정 행위는 청구인의 권리·의무에 영향을 미치는 행정처분에 해당하므로 이에 대한 다툼은 행정심판이나 행정소송에 의하여 구제되어야 한다. 그런데 청구인이 이러한 구제절차를

거쳤음을 인정할 자료가 없으므로, 이 부분 심판청구는 보충성 요건을 갖추지 못하였다.

바. 이 사건 제2열람 제한 행위는 금치처분에 따라 부과된 처우제한으로서, 이에 대한 청구인의 주장은 금치처분의 위헌성을 다투는 취지에 불과하다. 금치처분은 행정처분에 해당하여 행정심판 및 행정소송의 대상이 되는데, 청구인이 이러한 구제절차를 거쳤음을 인정할 자료가 없으므로, 이 부분 심판청구는 보충성 요건을 갖추지 못하였다.

【참조조문】

헌법재판소법 제25조 제3항 본문, 제68조 제1항 단서, 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8728호로 전부개정된 것) 제24조 제1항, 제104조 제1항, 제107조 제1호, 제108조 제7호, 제14호, 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률(2020. 2. 4. 법률 제16925호로 개정된 것) 제112조 제3항, 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙(2008. 12. 19. 법무부령 제655호로 제정된 것) 제194조 제3호, 제195조 제1항 제1호, 제196조 제1항, 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙(2013. 4. 16. 법무부령 제788호로 개정된 것) 제196조 제3항, 제4항, 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙(2014. 11. 17. 법무부령 제831호로 개정된 것) 제210조, 제211조 제1항, 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙(2010. 5. 31. 법무부령 제700호로 개정된 것) 제215조 제1호

【참조판례】

가. 헌재 2019. 2. 28. 2015헌마1204, 판례집 31-1, 141, 151 / 나. 헌재 2009. 12. 29. 2008헌마421, 공보 159, 139, 140-141, 헌재 2011. 2. 24. 2009헌마209, 판례집 23-1상, 157, 164 / 다. 헌재 2011. 2. 24. 2009헌마209, 판례집 23-1상, 157, 164 / 라. 헌재 2011. 2. 24. 2009헌마209, 판례집 23-1상, 157, 164, 헌재 2012. 3. 29. 2010헌마599, 판례집 24-1상, 631, 640 / 마. 헌재 2011. 2. 24. 2009헌마209, 판례집 23-1상, 157, 164 / 바. 헌재 2009. 12. 29. 2008헌마421, 공보 159, 139, 140-141, 헌재 2011. 2. 24. 2009헌마209, 판례집 23-1상, 157, 164

【전문】

【청 구 인】 김○○ (국선대리인 변호사 강재룡)

【피청구인】 ○○교도소장 외 1인

【주문】

이 사건 심판청구를 모두 각하한다.

【이유】

1. 사건개요

가. 청구인은 강간상해, 성폭력범죄의처벌및피해자보호등에관한법률위반(특수강도강간등), 특정범죄가중처벌등

에 관한 법률위반(강도상해등재범)의 범죄사실로 징역 17년을 선고받고 2010. 5. 13. 그 형이 확정된 사람으로 형기 종료 예정일은 2027. 2. 2.이다.

나. 청구인은 2009. 6. 11. ○○구치소에 입소하였다가 2010. 7. 5. △△교도소로, 2011. 7. 13. ▽▽교도소로, 2013. 12. 17. ◇◇교도소로, 2018. 12. 7. ○○교도소로, 2020. 10. 8. □□교도소로, 2021. 5. 17. ◎◎교도소로 각 이송되어 이 사건 심판청구 당시까지 ◎◎교도소에 수용 중이었다.

다. 청구인은 ① ○○교도소장이 2020. 9. 10. 청구인에 대하여 한 금치 21일 처분, ② □□교도소장이 2021. 5. 10. 청구인에 대하여 한 관심대상수용자 지정 행위, ③ □□교도소장이 2021. 5. 13. 청구인에 대하여 한 금치 30일 처분, ④ 법무부장관이 2021. 5. 17. 청구인에 대하여 한 ◎◎교도소 이송 처분, ⑤ 금치 기간 중 도서 열람 제한, ⑥ 외부 물품(변색렌즈 안경 등) 반입 불허, ⑦ ○○교도소장의 2020. 10. 23.자 정보 비공개 결정, ⑧ ○○교도소장의 2020. 10. 29.자 정보 부분 공개 결정, ⑨ ○○교도소장의 2021. 6. 24.자 정보 비공개 결정, ⑩ 토요일 화상 접견과 예약 접견을 제한한 행위로 인하여 청구인의 기본권이 침해되었다고 주장하면서 2021. 8. 9. 이 사건 헌법소원심판을 청구하였다.

라. 청구인의 국선대리인은 2021. 10. 27. 청구이유 보충서를 통하여 피청구인 ○○교도소장이 수감 기간에 청구인에 대하여 의료용품 사용을 불허한 처분, 외부 용품(자동 인식 스마트워치, 변색 안경, 저주파 치료기) 소지 신청을 불허한 행위, 2020. 9. 10. 청구인에 대하여 부과한 금치 21일 처분, 정보공개 청구에 대한 비공개 결정을 한 행위, 토요일 화상 접견과 예약 접견을 제한한 행위, 영상계호 거실에 수용한 행위, 2020. 11. 9. 청구인에 대하여 부과한 금치 기간 중 도서 열람 제한 조치, 피청구인 □□교도소장이 2021. 5. 10. 청구인을 엄중관리대상자로 지정한 처분, 피청구인 ◎◎교도소장이 2021. 5. 13.부터 5. 27.까지 청구인에 대하여 부과한 금치 기간 중 도서 열람 제한 조치는 청구인의 기본권을 침해한다는 결정을 구하는 것으로 청구취지를 확정하였다.

2. 심판대상

가. 헌법재판소법 제25조 제3항 본문은 “각종 심판절차에서 당사자인 사인(사인)은 변호사를 대리인으로 선임하지 아니하면 심판청구를 하거나 심판 수행을 하지 못한다.”라고 규정하고 있다. 따라서 변호사의 자격이 없는 사인인 청구인이 한 헌법소원 심판청구나 주장은 변호사인 대리인이 추인한 경우에 한하여 효력이 있고, 추인이 없는 한 대리인의 심판청구서에 기재되어 있지 아니한 청구인의 그 전의 심판청구의 내용은 심판대상이 되지 않는다(헌재 2017. 9. 28. 2016헌마964 참조). 따라서 이 사건에서는 국선대리인이 제출한 청구이유 보충서의 내용을 기준으로 심판대상을 확정하기로 한다.

나. 헌법소원 심판청구서에서 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 경우에도 헌법소원의 적법요건에 흠결이 있는 것은 아니므로 직권으로 피청구인을 확정할 수 있다(헌재 2008. 12. 26. 2007헌마775 참조).

국선대리인은 피청구인으로 법무부장관, ○○교도소장, □□교도소장, ◎◎교도소장을 특정하였으나, 법무부장관의 어떠한 공권력 행사가 청구인의 기본권을 침해한다는 것인지 구체적으로 주장하고 있지 않다. 또한 국선대리인은 ‘2021. 5. 13.부터 5. 27.까지 청구인에 대하여 부과된 금치 기간 중 도서 열람 제한 조치’를 문제 삼으며 ◎◎교도소장을 피청구인으로 적시하고 있으나, ◎◎교도소장의 2021. 10. 5.자 의견서 및 □□교도소장의 2021. 10. 12.자 의견서에 의하면 청구인은 2021. 5. 13. □□교도소에서 금치처분을 받고 2021. 5. 17. ◎◎교도소로 이송되었으므로 위와 같은 행위의 주체는 □□교도소장이고, ◎◎교도소장은 위 행위의 주체가 아님이 명백하며, 국선대리인이 ◎◎교도소장의 다른 공권력 행사를 다투는 것도 아니다. 그러므로 법무부장관과 ◎◎교도소장은 피청구인으로 삼지 않는다.

또한 국선대리인은 ‘2020. 11. 9. 청구인에 대하여 부과한 금치 기간 중 도서 열람 제한 조치’를 문제 삼으며 ○○교도소장을 피청구인으로 적시하고 있으나, 청구인은 위 시점에 □□교도소에 수용되어 있었으므로 위 조치에 대한 심판청구의 피청구인을 □□교도소장으로 확정한다.

다. 그렇다면 이 사건 심판대상은 ① 피청구인 ○○교도소장이 2020. 6. 18. 자동 인식 스마트워치 및 저주파 치료기 사용·소지 신청을 불허한 행위(이하 ‘이 사건 제1사용·소지 불허가 행위’라 한다), ② 피청구인 ○○교도소장이 2020. 9. 10. 청구인에 대하여 부과한 금치 21일 처분(이하 ‘이 사건 금치처분’이라 한다), ③ 피청구인 ○○교도소장이 2020. 9. 23. 변색 안경 사용·소지 신청을 불허한 행위(이하 ‘이 사건 제2사용·소지 불허가 행위’라 한다), ④ 피청구인 ○○교도소장의 2020. 10. 23.자 정보 비공개 결정(이하 ‘이 사건 제1비공개

결정'이라 한다), ⑤ 피청구인 ○○교도소장의 2020. 10. 29.자 정보 부분 공개 결정(이하 '이 사건 부분 공개 결정'이라 한다), ⑥ 피청구인 ○○교도소장의 2021. 6. 24.자 정보 비공개 결정(이하 '이 사건 제2비공개 결정'이라 한다), ⑦ 피청구인 ○○교도소장이 토요일 화상 접견과 예약 접견을 제한한 행위(이하 '이 사건 접견 제한 행위'라 한다), ⑧ 피청구인 ○○교도소장이 청구인을 영상게호 거실에 수용하여 게호한 행위(이하 '이 사건 게호 행위'라 한다), ⑨ 피청구인 □□교도소장이 2020. 11. 9. 청구인에 대하여 부과한 금치 기간 중 도서 열람 제한 행위(이하 '이 사건 제1열람 제한 행위'라 한다), ⑩ 피청구인 □□교도소장이 2021. 5. 10. 청구인을 관심대상수용자로 지정한 행위(이하 '이 사건 지정 행위'라 한다), ⑪ 피청구인 □□교도소장이 2021. 5. 13.부터 5. 27.까지 청구인에 대하여 부과한 금치 기간 중 도서 열람 제한 행위(이하 '이 사건 제2열람 제한 행위'라 한다)가 청구인의 기본권을 침해하는지 여부이다. 관련조항은 [별지]와 같다.

3. 청구인의 주장

가. 이 사건 제1, 제2사용·소지 불허가 행위는 청구인의 건강 상태가 악화되었음에도 특별한 이유 없이 이루어진 것으로 인간의 존엄과 가치, 행복추구권을 침해한다.

나. 이 사건 금치처분은 '형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률'(이하 '형집행법'이라 한다) 제116조가 규정한 교정시설의 장(이하 '소장'이라 한다)과의 면담 등 방어권 행사를 보장하지 않고 부과된 것이므로 자기방어권, 인간의 존엄과 가치, 행복추구권, 평등권을 침해한다.

다. 이 사건 제1, 제2비공개 결정 및 이 사건 부분 공개 결정, 이 사건 접견 제한 행위, 이 사건 게호 행위, 이 사건 지정 행위는 인간의 존엄과 가치, 행복추구권, 평등권을 침해한다.

라. 이 사건 제1, 제2열람 제한 행위는 금치 기간 중이라는 이유만으로 도서 열람을 제한하여 인간의 존엄과 가치, 행복추구권을 침해하고, 금치처분을 받은 재소자와 금치처분을 받지 않은 재소자를 차별하여 평등권을 침해한다.

4. 이 사건 제1사용·소지 불허가 행위, 이 사건 접견 제한 행위, 이 사건 게호 행위, 이 사건 제1열람 제한 행위에 관한 심판청구에 대한 판단

헌법소원의 대상이 되는 공권력의 행사 또는 불행사의 사실이 아예 존재하지 아니하는 경우에는 그 심판청구는 부적법하다(헌재 2019. 2. 28. 2015헌마1204).

피청구인 ○○교도소장의 2021. 10. 12.자 의견서 및 그에 첨부된 '동태 관찰 사항'에 의하면, 피청구인 ○○교도소장은 2019. 2. 12. 청구인의 저주파 치료기 사용 신청을 허가하여 개인용 저주파 치료기를 지급한 것으로 보이고, 달리 기록상 피청구인 ○○교도소장이 자동 인식 스마트워치 사용·소지 신청을 불허하거나, 토요일 화상 접견과 예약 접견을 제한하거나, 청구인을 영상게호 거실에 수용하여 게호하거나, 피청구인 □□교도소장이 2020. 11. 9. 도서 열람을 제한한 사실을 인정할 만한 자료가 없다. 따라서 이 부분 심판청구는 모두 헌법소원의 대상이 되는 공권력의 행사가 존재하지 아니하여 부적법하다.

5. 나머지 심판청구에 대한 판단

가. 헌법소원심판의 보충성

헌법소원심판은 다른 법률에 구제절차가 있는 경우에는 그 절차를 모두 거친 후에 청구할 수 있으므로(헌법재판소법 제68조 제1항 단서), 행정상의 각종 처분에 대하여 행정소송으로 이를 다룰 수 있다면 반드시 그 절차를 거쳐야 하고, 그렇지 않은 채 헌법소원심판이 제기되었으면 이는 부적법하다(헌재 2011. 2. 24. 2009헌마209 참조).

나. 이 사건 금치처분에 관한 심판청구

소장은 수용자가 형법, '폭력행위 등 처벌에 관한 법률', 그 밖의 형사 법률에 저촉되는 행위를 하면 징벌위원회의 의결에 따라 21일 이상 30일 이하의 금치에 처할 수 있는데(형집행법 제107조 제1호, 제108조 제14호, 같은 법 시행규칙 제215조 제1호 참조), 이러한 금치처분은 형집행법 제107조에 의한 행정처분에 해당하여 행정심판 및 행정소송의 대상이 되므로 이를 통하여 그 적법 여부를 다룰 수 있다(헌재 2009. 12. 29. 2008헌마421 참조). 그런데 기록을 살펴봐도 청구인이 이러한 구제절차를 거쳤음을 인정할 자료가 없다. 따라서 이 부분 심판청구는 보충성 요건을 갖추지 못하여 부적법하다.

다. 이 사건 제2사용·소지 불허가 행위에 관한 심판청구

형집행법 제24조 제1항에 의하면, 수용자는 소장의 허가를 받아 자신의 비용으로 음식물·의류·침구, 그 밖에

수용생활에 필요한 물품을 구매할 수 있다. 이에 청구인에게는 소장에게 자비에 의한 물품 구매를 요구할 법률상 신청권이 인정되므로 이를 거부하거나 방치한 행위는 행정심판 및 행정소송의 대상이 된다. 그런데 기록을 살펴보아도 청구인이 이 사건 제2사용·소지 불허가 행위에 대하여 행정심판 및 행정소송 등의 구제절차를 거쳤음을 인정할 자료가 없다. 따라서 이 부분 심판청구는 보충성 요건을 갖추지 못하여 부적법하다.

라. 이 사건 제1, 제2비공개 결정 및 이 사건 부분 공개 결정에 관한 심판청구

‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’은 정보공개 청구인이 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복이 있는 때에는 이의신청(제18조), 행정심판(제19조), 행정소송(제20조)의 구제절차를 밟을 수 있도록 규정하고 있다. 그런데 기록을 살펴보아도 청구인이 이 사건 제1, 제2비공개 결정 및 이 사건 부분 공개 결정에 대하여 이의신청이나 행정심판 및 행정소송 등의 구제절차를 거쳤음을 인정할 자료가 없다. 따라서 이 부분 심판청구는 보충성 요건을 갖추지 못하여 부적법하다(헌재 2012. 3. 29. 2010헌마599 참조).

마. 이 사건 지정 행위에 관한 심판청구

피청구인 □□교도소장은 형집행법 제104조 제1항, 같은 법 시행규칙 제194조 제3호, 제210조 및 제211조 제1항에 따라 청구인을 관심대상수용자로 지정하였다. 소장은 관심대상수용자에 대하여는 교정시설의 안전과 질서유지를 위해 다른 수용자와의 접촉을 차단하거나 계호를 엄중히 하는 등 다른 수용자와 달리 관리할 수 있다(형집행법 제104조 제1항, 같은 법 시행규칙 제194조 제3호 참조).

구체적으로, 소장은 관심대상수용자가 변호인 외의 자에게 편지를 보내려는 경우로서 금지물품의 확인을 위하여 필요한 경우에는 편지를 봉합하지 않은 상태로 제출하게 할 수 있고, 관심대상수용자가 다른 수용자와 편지를 주고받는 때에는 그 내용을 검열할 수 있으며, 교도관에게 거실 등을 수시로 검사하게 할 수 있다(형집행법 시행령 제65조 제1항 제1호, 제66조 제1항 제1호, 제112조).

또한 관심대상수용자로 지정되는 경우, 일반 수용자들과 달리 노란색 번호표 및 거실표를 달게 되고, 지속적인 상담이 필요하다고 인정되는 경우 상담책임자가 지정되어 수시로 개별상담을 받게 되고 상담 요지와 처리 결과 등이 교정정보시스템에 입력되어 상담결과 보고서의 형태로 소장에게 보고될 수 있으며, 원칙적으로 독거수용되어 운동·목욕·이발을 단독으로 실시하게 될 뿐 아니라, 종교집회 등에 참석할 경우에도 다른 수용자와 좌석이 분리된다(형집행법 시행규칙 제195조 제1항 제1호, 제196조 제1항, 제3항, 제4항, ‘수용관리 및 계호업무 등에 관한 지침’ 제15조, 제16조, 제19조 제1항).

이처럼 관심대상수용자로 지정되면 편지 수수, 생활, 상담 등의 측면에서 일반 수용자들과는 다른 처우를 받을 수 있는 지위에 놓이게 된다. 즉, 이 사건 지정 행위는 청구인의 권리·의무에 영향을 미치므로, ‘행정청이 행하는 구체적 사실에 대한 법집행으로서의 공권력의 행사’로서 행정소송법상 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다. 따라서 이에 대한 다툼은 행정심판이나 행정소송에 의하여 구제되어야 한다.

그런데 기록을 살펴보아도 청구인이 이 사건 지정 행위에 대하여 행정심판 및 행정소송 등의 구제절차를 거쳤음을 인정할 자료가 없으므로, 이 부분 심판청구는 보충성 요건을 갖추지 못하여 부적법하다.

바. 이 사건 제2열람 제한 행위에 관한 심판청구

청구인이 문제 삼고 있는 이 사건 제2열람 제한 행위는, 피청구인 □□교도소장이 2021. 5. 13. 청구인에게 금지 30일 처분을 부과함에 따라 형집행법 제112조 제3항, 제108조 제7호에 따라 부과된 처우제한으로서, 이에 대한 청구인의 주장은 결국 해당 처우제한의 실질적 근거가 된 위 금지처분의 위헌성을 다투는 취지에 불과하다. 위 금지처분은 행정소송법상 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하므로, 그에 대한 다툼은 행정심판이나 행정소송에 의하여 구제되어야 한다(헌재 2009. 12. 29. 2008헌마421 참조). 그런데 기록을 살펴보아도 청구인이 행정심판 및 행정소송 등의 구제절차를 거쳤음을 인정할 자료가 없다. 따라서 이 부분 심판청구는 보충성 요건을 갖추지 못하여 부적법하다.

6. 결론

그렇다면 이 사건 심판청구는 모두 부적법하므로 이를 각하하기로 하여, 관여 재판관 전원의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.

재판관 김상환 김형두 정정미 정형식 김복형 조한창 정계선 마은혁 오영준